14. 배당절차

가. 총설

매각대금으로부터 변제받을 채권자가 1인뿐이거나 여러 채권자가 경합되어 있더라도 매각대금이 집행비용 및 각 채권자의 채권을 만족시키기에 충분한 경우에는 집행법원은 각 채권자에게 그 채권액을 교부(변제)하고 잔액이 있으면 채무자에게 교부할 것이고, 변제받을 채권자들이 경합되어 있고 매각대금으로 채권자들의 채권을 만족시키기에 충분하지 않은 경우에는 법원이 각 채권자들에게 민·상법, 그 밖의 법률에 의한 우선순위에 따라 매각대금을 배당하여야 한다.

따라서 이론상으로는 매각대금으로 각 채권자를 만족시킬 수 있는 경우에 실시하는 변제절차와 각 채권자를 만족시킬 수 없는 경우에 실시하는 변제절차가 서로 구별될 것이나, 어느 것이나 모두 넓은 의미에서는 배당절차라 할 것이고, 또 민사집행법도 양자를 엄격히 구별하고 있지 않으므로 실제로는 전자의 경우에도 후자의 경우와 똑같이 배당기일을 지정하고 배당표를 작성하여 배당을 실시한다.

동산집행에서는 배당절차개시요건이 구비되면 종전의 집행절차와는 별도의 독립한 채권배당사건(타배)으로서 배당절차가 개시되므로 그 절차에 독립한 사건번호를 부여하고 기록도 따로 편성하지만, 부동산경매에 관해서는 배당절차가 종전의 경매절차의 일환으로 실시되므로 별도의 사건번호가 부여되는 것도 아니고 또 별도의 기록이 편성되는 것도 아니다.

나. 배당요구

(1) 배당요구의 의의

배당요구란 다른 채권자에 의하여 개시된 집행절차에 참가하여 동일한 재산의 매각대금에서 변제를 받으려는 집행법상의 행위로서 다른 채권자의 강제집

84-10 문 11.). 건물과 대지가 따로 매각되는 경우 소액임차인은 먼저 매각되는 목적물의 매각대금의 1/2 한도 안에서 우선변제를 받고 만일 잔여보증금이 있으면 후에 매각되는 목적물의 매각대금 1/2의 한도 안에서 다시 우선변제를 받는다(재민 84-10 문 14.).

상가건물의 경우에도 위에 기술한 내용이 그대로 적용된다.

(카) 매수인에게 인수되는 보증금의 범위

주택임대차보호법상의 대항력과 우선변제권의 두 가지 권리를 겸유하고 있는 임차인이 우선변제권을 선택하여 임차주택에 대하여 진행되고 있는 매각절차에서 보증금 전액에 대하여 배당요구를 하였으나 그 순위에 따른 배당이 실시되어 보증금 전액을 배당받을 수 없었던 경우 매수인에게 대항할 수 있는 보증금 잔액은 보증금 중 매각절차에서 올바른 배당순위에 따른 배당이 실시될 경우의 배당액을 공제한 나머지 금액을 의미하는 것이지 임차인이 배당절차에서 현실로 배당받은 금액을 공제한 나머지 금액을 의미하는 것은 아니다. 따라서 임차인이 배당받을 수 있었던 금액이 현실로 배당받은 금액보다 많은 경우에는 임차인은 그 차액에 관하여는 과다 배당받은 후순위 배당채권자를 상대로 부당이득의 반환을 구하는 것은 별론으로 하고 매수인을 상대로 그 반환을 구할 수는 없다(대판 2001. 3. 23. 2000다30165). 예를 들어, 집행법원이 임차인에게 보증금 전액인 1,000만 원 중 800만 원을 배당하여야 함에도 불구하고 500만 원만을 배당하여 그 배당표가 확정된 경우(현실로 배당받은 금액이 적은 경우) 임차인은 매수인에게 실제 배당받은 금액을 공제한 잔액 500만 원의 지급을 구할 수는 없고, 정당하게 배당받을 수 있었던 금액을 공제한 잔액 200만 원의 지급만을 구할 수 있다.

그리고 위의 경우에 매수인에게 인수되는 보증금은 대항력 있는 보증금 즉 보증금이 인상된 경우 후순위의 담보권자나 가압류권자가 생기기 전까지의 보증금을 한도로 함은 당연하다.

주택 경매절차의 매수인이 권리신고 및 배당요구를 한 주택임차인의 배당순위가 1순위 근저당권자보다 우선한다고 신뢰하여 임차보증금 전액이 매각대금

다'고 규정하고 있으므로 이에 따라야 하는데, 다만 이 조항은 공익채권이 회사의 일반재산으로부터 변제를 받는 경우에 우선한다는 의미이지, 회생담보권이 설정된 특정재산의 매각대금으로부터도 우선변제를 받는다는 의미는 아니며, 회생담보권이 설정된 재산 위에 공익담보권이 설정된 경우에는 회생담보권이 우선함을 주의하여야 한다(대판 1993. 4. 9. 92다56216). 또한 회생계획이 정한 징수 유예기간이 지난 후 회생채권인 조세채권에 기하여 국세징수법에 의한 체납처분이 이루어진 경우, 국세기본법 35조 1항에 따라 국세의 우선권이 보장되는 체납처분에 의한 강제환가절차에서는 회생채권인 조세채권이라 하더라도 공익채권보다 우선하여 변제된다(대판 2012. 7. 12. 2012다23252 참조).

회생채무자에 대한 회생절차가 개시된 후 관리인의 공익채권 이행지체로 인하여 생긴 손해배상청구권도 공익채권에 해당한다[대판 2004. 11. 12. 2002다53865, 대판 2011. 6. 24. 2009다38551, 대판(전) 2014. 11. 20. 2013다64908].

(나) 파산재단에 속하는 부동산이 매각된 경우

1) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 475조가 재단채권은 파산절차에 의하지 아니하고 수시로 이를 변제한다고 규정하고 있음에도 불구하고 파산채권이나 재단채권 모두 파산절차에 의하지 아니하고는 변제받을 수 없고, 따라서 파산채권·재단채권에 기하여 독립하여 강제집행을 하거나 배당요구할 수 없다는 것이 통설이다. 이에 의하면 집행법원은 이들 채권에 대하여 배당을 실시할 여지가 없고, 단지 별제권은 파산절차에 의하지 아니하고 이를 행사할 수 있으므로(채무자 회생 412조), 파산재단에 속하는 부동산에 대한 경매절차에서는 그것이 어떤 사유로 개시된 것이든(설령 파산채권에 기하여 개시된 것으로서 파산관재인이 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 348조 1항 단서에 의하여 파산재단을 위하여 그 절차를 속행한 경우에도) 경매법원은 별제권자에게만 지급할 수 있을 뿐이다.

다만 ㉠ 주택임대차보호법 3조 1항의 규정에 의한 대항요건을 갖추고 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 임차인과 같은 법 8조의 규정에 의한 소액임차인(이 경우 임차인은 파산신청일까지 주택임대차보호법 3조 1항의 규정에 의한

대항요건을 갖추어야 한다), ㉡ 상가건물 임대차보호법 3조의 규정에 의한 대항요건을 갖추고 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 임차인과 같은 법 14조의 규정에 의한 소액임차인은 파산재단에 속하는 주택(대지를 포함한다)의 환가대금에서 그 우선순위에 따라 배당받을 수 있다(채무자회생 415조). ㉢ 근로기준법 38조 2항 각 호에 따른 채권과 근로자퇴직급여 보장법 12조 2항에 따른 최종 3년간의 퇴직급여 등 채권의 채권자는 파산재단에 속하는 재산에 대한 별제권 행사 또는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 349조 1항의 체납처분에 따른 환가대금에서 우선하여 변제받을 수 있다[2014. 12. 30. 개정(2015. 7. 1. 시행)된 채무자회생 415조의2 본문 참조. 다만 채무자회생 415조의2의 개정 규정은 이 법 시행 후 최초로 발생하는 임금, 재해보상금, 퇴직금 등 근로관계로 인한 채권부터 적용한다(부칙 3조)]. 따라서 위와 같은 경우 채권자(임차인, 임금채권자)는 파산재단에 속하는 재산에 대한 별제권 행사에 따른 경매절차에서 배당요구를 할 수 있고, 그 채권에 대한 배당은 배당요구를 한 채권자에게 직접 한다. 그러나 근로복지공단이 체당금을 지급하여 근로자의 임금 등 채권을 대위하는 자격에서 배당요구를 한 경우에는 그 배당액을 근로복지공단에 지급할 수 없고 파산관재인에게 교부한다(채무자회생 415조의2 단서 참조).

그리고 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 348조 1항 단서에 의하여 속행된 경우에는 집행비용은 재단채권이 되므로(채무자회생 348조 2항 전단) 별제권자에게 배당하고 남은 나머지 전부, 즉 집행비용을 포함한 잔금 전액을 파산관재인에게 교부하여야 하고, 별제권행사에 의하여 개시되었거나 속행된 경우에는 별제권의 원리금뿐만 아니라 집행비용도 별제권자에게 배당하고, 그 나머지를 파산관재인에게 교부한다. 실무상으로는 배당표의 채권자란에는 배당요구권자를 기재하고 바로 뒤에 '(파산관재인에게 교부)'라고 기재한다.

근로자의 임금·퇴직금 및 재해보상금은 그 발생시기가 파산선고 전후인지 여부를 불문하고 모두 재단채권이 된다(채무자회생 473조 10호). 재단채권은 파산절차에 의하지 않고 파산관재인이 수시로 변제하여야 하지만(채무자회생 475조), 임금채권 등 재단채권에 기하여 파산선고 전에 강제집행이 이루어진 경우

없다고 한다면 개인회생절차의 진행이 방해되거나 개인회생채권자 일반의 이익에 반하는 경우가 생길 수 있다. 따라서 개인회생절차개시결정이 있으면 담보권 실행을 중지 또는 금지하되, 다만 위 중지·금지는 '변제계획의 인가결정일 또는 개인회생절차 폐지결정의 확정일 중 먼저 도래하는 날'까지만 적용되도록 규정하였다(채무자회생 600조 2항).

한편 개인회생절차개시결정으로 인하여 개인회생채권에 기한 강제경매절차나 담보권 실행을 위한 경매절차가 중지되더라도, 법원은 상당한 이유가 있는 때에는 이해관계인의 신청에 의하거나 직권으로 위와 같이 중지된 경매절차의 속행을 명할 수도 있다(채무자회생 600조 1항, 2항, 3항 본문).

결국 ① 개인회생절차개시결정으로 중지되었던 개인회생채권에 기한 강제경매절차 또는 담보권 실행을 위한 경매절차가 법원의 속행명령에 따라 속행되는 경우, ② 변제계획의 인가결정일 이후 직권으로 또는 별제권자 등의 신청에 따라 담보권 실행을 위한 경매절차가 속행되는 경우에는 별제권자, 개인회생채권자, 개인회생재단채권자 등에 대한 배당이 문제될 수 있다.

2) 별제권자는 개인회생절차의 변제계획에 의하지 않고 채권의 만족을 얻을 수 있으므로, 경매법원은 별제권자에게 배당금을 직접 지급하는 것으로 배당표를 작성하면 된다. 근저당권인 경우에는 채권최고액 범위 내에서 배당을 실시한다.

피담보채권이 근저당권의 채권최고액을 초과하는 경우 별제권의 행사에 의하여 변제를 받을 수 없는 채권액에 관하여는 개인회생채권자로서 그 권리를 행사할 수 있을 뿐이므로(채무자회생 586조, 413조 본문), 위 초과 부분을 별제권자에게 직접 배당할 수는 없다. 실무상 별제권 행사로 변제받지 못할 것으로 예상되는 부분을 미리 변제계획에 미확정채권으로 설정하고 그에 해당하는 변제금을 유보해 두면서 그 유보금에 대한 처리절차도 함께 정하는 것이 일반적인데, 만일 위 초과 부분이 미확정채권 범위 내라면 변제계획에 정한 유보금 배분절차를 거치게 되나 위 초과 부분이 미확정채권의 범위를 넘는다면 변제계획안 변경절차(채무자회생 619조)를 거쳐야 한다. 따라서 어느 경우든 위 초과 부분에 해당하는 배당금은 채무자에게 지급하여야 한다.

3) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 586조는 파산절차에 관한 같은 법 415조를 준용하고 있다. 따라서 ㉠ 주택임대차보호법 3조 1항의 규정에 의한 대항요건을 갖추고 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 임차인과 같은 법 8조의 규정에 의한 소액임차인, ㉡ 상가건물 임대차보호법 3조 1항의 규정에 의한 대항요건을 갖추고 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 임차인과 같은 법 14조의 규정에 의한 소액임차인에 대하여는 개인회생재단에 속하는 주택 및 대지의 환가대금에서 그 우선순위에 따라 직접 배당한다.

한편 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 586조가 일부 임금 등 채권에 관한 같은 법 415조의2를 준용하고 있지는 않다. 그러나 임금 등 채권은 개인회생재단채권으로서(채무자회생 583조 1항 3호 참조) 개인회생재단채권은 개인회생절차에 의하지 않고 수시로 변제하며 개인회생채권보다 먼저 변제한다(채무자회생 583조 2항, 476조, 477조). 나아가 파산절차와는 달리 개인회생절차에서는 재단부족의 경우 변제방법에 관한 같은 법 477조를 준용하지 않고 있다. 따라서 임금 등 채권자에게 직접 배당함이 타당하다. 마찬가지로 다른 개인회생재단채권의 경우에도 그 채권자에게 직접 배당한다.

다만 개인회생재단채권을 개인회생채권보다 먼저 변제한다는 규정(채무자회생 476조, 583조 2항)은 별제권에 의하여 담보된 재산을 제외한 채무자의 일반재산으로부터 변제를 받는 경우 개인회생재단채권이 개인회생채권에 우선한다는 의미이다. 따라서 별제권이 설정된 재산에 대하여 경매절차가 진행되는 경우 그 배당순위는 민사집행법 145조 2항이 규정한 바와 같이 민법·상법, 그 밖의 법률에 의한 우선순위에 따르게 된다.

4) 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권은 변제계획에 의하지 않고는 변제받을 수 없다(채무자회생 582조). 따라서 그러한 채권자에 대하여는 직접 배당할 수 없고 채무자에게 지급하게 된다.

개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권에 해당하는 조세채권 등의 경우, 개인회생절차개시결정 전에 일정한 조세채권 등에 기한 체납처분이 마쳐졌다면, 개시결정으로 인하여 그 체납처분 절차가 중지되고(채무자회생 600조 1항

4호), 위와 같이 중지된 체납처분은 변제계획 인가결정에 의해서도 실효되지 않으며(채무자회생 615조 3항 참조), 오히려 변제계획 인가결정 이후 속행이 가능하므로, 그 조세채권자에게 직접 배당하여야 한다는 견해가 있다. 그러나 다른 개인회생채권의 경우와 달리 취급할 이유가 없으므로 채무자에게 배당하면 된다. 다만 개인회생채권자목록에 기재되지 않은 경우에는 개인회생절차개시결정 또는 변제계획 인가결정 등의 효력 자체가 문제되지 않으므로 조세채권자에게 직접 배당하여야 할 것이다.

타. 배당기일의 실시

(1) 배당표의 확정

법원은 미리 작성한 배당표원안을 배당기일에 출석한 이해관계인과 배당을 요구한 채권자에게 보여주고 그들을 심문하여 그 의견을 듣고 또 즉시 조사할 수 있는 증거를 조사한 다음 이에 기하여 배당표원안에 추가, 정정할 것이 있으면 추가, 정정하여 배당표를 완성·확정한다(민집 149조 2항, 152조 2항).

배당표에 대하여 이의가 있으면 그 이의 있는 부분에 한하여 배당표는 확정되지 않는다(민집 152조 3항 참조).

배당기일에 출석한 이해관계인과 배당을 요구한 채권자가 합의한 때에는 이에 따라 배당표를 작성하여야 한다(민집 150조 2항).

배당표에 대하여 이해관계인이나 배당요구채권자의 이의가 없어 그대로 확정되면 법원 및 각 채권자와 채무자는 이에 기속된다.

(2) 차액지급 또는 채무인수 시의 잔여액의 납부

① 매수인이 대금의 지급에 갈음하여 채무인수(민집 143조 1항)를 신청하였거나 또는 채권자인 매수인이 차액지급신고(민집 143조 2항)를 한 경우에는 매각대금에서 인수하거나 매수인이 배당받을 금액을 제외한 나머지 금액을 배당기일에 내야 한다.

므로 소를 유지하는 것은 불가능하지만 실체상의 권리를 잃는 것은 아니므로 부당이득반환청구소송으로 변경하여야 한다고 한다.

한편 배당이의의 소가 소정의 기간 내에 제기되었으나 소제기증명서를 소정기간 경과 후에 제출한 경우에, 집행법원으로서는 아직 배당이 실시되지 아니하였더라도, 이를 기간을 준수하여 증명한 것과 마찬가지로 취급할 수 없다고 함은 앞에서 본바와 같다[전술한 **타. (4) (다) 7) 배당이의의 소제기 등의 증명** 참조].

(다) 관할법원

배당이의의 소는 배당을 실시한 집행법원이 속한 지방법원의 관할로 한다(민집 156조 1항 본문). 이는 전속관할이다(민집 21조). 여기서 지방법원은 반드시 본원만을 뜻하는 것은 아니다. 한편 법원조직법은 지방법원 및 그 지원의 심판권을 원칙적으로 단독판사가 행사하도록 하고 있으므로(법조 7조 4항), 심판권은 원칙적으로 단독판사에 속한다. 다만 소송물이 단독판사의 관할에 속하지 아니할 경우에는 지방법원의 합의부가 이를 관할한다(민집 156조 1항 단서).

여러 개의 배당이의의 소가 제기된 경우에 한 개의 소를 합의부가 관할하는 때에는 그 밖의 소도 함께 관할한다(민집 156조 2항).

그런데 전속관할의 경우는 원래 합의관할(민소 29조), 변론관할(민소 30조)의 적용이 배제되나(민소 31조) 배당이의의 소에서는 예외적으로, 이의한 사람과 상대방이 이의에 관하여 단독판사의 재판을 받을 것을 합의한 경우에는 민사집행법 156조 1항 단서와 2항의 규정에 의하여 합의부관할에 속하는 사건도 단독판사가 재판할 수 있다(민집 156조 3항).

(라) 소의 이익과 당사자적격

① 소의 이익

㉮ 채권자가 배당이의의 소를 제기하기 위해서는 그 이의가 인용되면 자기의 배당액이 증가되는 경우이어야 한다(대판 1994. 1. 25. 92다50270, 대판 2010. 10. 14. 2010다39215). 따라서 배당기일에 다른 채권자가 이의를 정당하다고 하거나 채권자들 사이에 배당에 관하여 다른 방법으로 합의가 성립된 때에는 그 채권자들 사이에는 이의권이 소멸되고 배당표는 확정되는 것이므로

소의 이익이 없게 된다. 이의가 있으면 배당법원은 그 부분에 대한 배당실시를 유보하고 배당표 가운데 이의가 없이 확정된 부분에 대하여 배당을 실시할 것이지만 배당법원의 잘못으로 이의의 대상이 된 부분까지 배당을 실시하여 버린 때에도 역시 소의 이익이 없게 된다(대판 1965. 5. 31. 65다647).

배당에 가입한 이상 원고나 피고의 채권이 민사소송사항에 속하지 아니하는 청구이거나 채무자와 사이에 중재계약이 존재하는 경우에도 배당이의의 소의 제기가 가능하다.

㉰ 현재 배당표상 배당을 받을 채권자가 아니라고 하더라도 배당이의의 소에서 승소하면 배당을 받을 수 있는 지위에 있는 채권자는 원고가 될 수 있다.

이와 관련하여 채권자가 제기한 배당이의소송에서 피고의 채권이 존재하지 않는 것으로 인정되는 경우 다툼이 있는 배당 부분 가운데 원고에게 귀속시키는 배당액을 계산할 때에 이의신청을 하지 아니한 다른 채권자의 채권을 참작할 필요가 없으며, 이는 이의신청을 하지 아니한 다른 채권자 가운데 원고보다 선순위의 채권자가 있다 하더라도 마찬가지이므로[자세한 것은 후술하는 (4) (다) **공격방어방법** 참조], 피고의 채권이 존재하지 않는 것으로 주장되는 이상 주장자체로서 원고의 배당액이 증가될 여지가 있으므로 소의 이익이 문제될 수 없다.

② **원고적격**

㉮ 원고로서의 당사자적격이 있는 자는 배당표에 대한 실체상의 이의를 한 채권자 또는 채무자인데, 그중 채권자는 반드시 배당기일에 출석하여 이의를 한 채권자만이 원고적격을 인정받지만(대판 1981. 1. 27. 79다1846), 채무자는 배당기일에 출석하여 이의를 한 경우뿐 아니라 배당기일에 불출석하였더라도 배당표원안이 비치된 이후에 배당기일이 끝날 때까지 서면으로 이의한 경우에도(민집 151조 1항, 2항 참조) 원고적격이 인정된다.

그러나 채권자가 이의를 한 경우에는, 이의를 한 이상 그가 집행력 있는 집행권원의 정본을 가지고 있는지 여부는 문제로 되지 아니하며, 가압류채권자도 모두 포함된다.

적법하게 배당요구를 하지 못한 채권자는 배당기일에 출석하여 배당표에 대

한 실체상의 이의를 신청할 권한이 없으므로 그러한 자가 배당기일에 출석하여 배당표에 대한 이의를 신청하였다고 하더라도 이는 부적법한 이의신청에 불과하고, 그 자에게는 배당이의의 소를 제기할 원고적격이 없다(대판 2003. 8. 22. 2003다27696).

제3자 소유의 물건이 채무자의 소유로 오인되어 강제집행목적물로서 매각된 경우에도 그 제3자는 경매절차의 이해관계인에 해당하지 아니하므로 배당기일에 출석하여 배당표에 대한 실체상의 이의를 신청할 권한이 없으며, 따라서 제3자가 배당기일에 출석하여 배당표에 대한 이의를 신청하였다고 하더라도 이는 부적법한 이의신청에 불과하고, 그 제3자에게 배당이의의 소를 제기할 원고적격이 없다(대판 2002. 9. 4. 2001다63155).

배당이의의 소의 원고적격이 있는 사람은 채무자 또는 배당기일에 출석하여 배당표에 대하여 이의를 진술한 채권자에 한하고, 다만 담보권 실행을 위한 경매에서 경매목적물의 소유자는 여기의 채무자에 포함된다. 그런데 진정한 소유자이더라도 경매개시결정등기 당시 소유자로 등기되어 있지 아니하였다면 민사집행법 90조 2호의 '소유자'가 아니고, 그 후 등기를 갖추고 집행법원에 권리신고를 하지 아니하였다면 같은 조 4호의 '부동산 위의 권리자로서 그 권리를 증명한 사람'도 아니므로, 경매절차의 이해관계인에 해당하지 않는다. 따라서 이러한 사람에게는 배당표에 대하여 이의를 진술할 권한이 없고, 이의를 진술하였더라도 이는 부적법한 것에 불과하여 배당이의의 소를 제기할 원고적격이 없다.

반면에 경매개시결정등기 당시 소유자로 등기되어 있는 사람은 설령 진정한 소유자가 따로 있는 경우일지라도 그 명의의 등기가 말소되거나 이전되지 아니한 이상 경매절차의 이해관계인에 해당하므로, 배당표에 대하여 이의를 진술할 권한이 있고, 나아가 그 후 배당이의의 소를 제기할 원고적격도 있다(대판 2015. 4. 23. 2014다53790).

㉰ 집행력 있는 집행권원의 정본 없이 배당요구를 한 채권자에 대하여 집행력 있는 집행권원의 정본을 가진 채권자가 이의를 한 경우에도 언제나 이의를 한 채권자가 소를 제기하지 않으면 안되는 것은 회생채권확정이나 파산채권확정의

매수신고인 등의 동의를 받아야 한다(민집규 49조 1항 참조).

③ 매각의 실시 후 매각허부결정 사이에 경매신청이 적법하게(최고가매수신고인 등의 동의를 얻어) 취하되면 경매절차는 당연히 종료되지만, 이 경우에도 취하의 시기나 효력이 다투어질 경우를 대비하고 관계인에 대하여 절차관계를 명확히 하여 주기 위하여, 집행을 계속 진행할 수 없는 때에 해당된다는 이유로(민집 121조 1호) 매각불허가결정을 하여야 한다는 견해가 있다.

매수인이 대금을 납부한 때에는 목적부동산의 소유권이 매수인에게 이전하기 때문에, 그 후의 취하는 허용되지 아니하고, 배당절차를 속행하면 된다.

그러나 압류채권자가 스스로 배당받을 권리를 포기할 수 있으므로, 대금지급 후에 취하서가 제출되면 실무에서는 취하를 한 압류채권자에게 그 취지를 확인하여 그 안에 배당을 받을 권리를 포기하는 의사가 들어 있을 경우에는 그에 따라 배당에서 제외하면 될 것이다.

④ 한편 강제경매절차에서 채무자가 청구이의의 소(민집 44조)를 제기하여 본안재판부로부터 집행정지결정(잠정처분)을 받은 다음 본안에서 승소판결을 받아 그 판결정본을 민사집행법 49조 1호의 취소서류로 집행법원에 제출한 경우, 임의경매절차에서 ㉠ 피담보채무액 전액을 변제받은 경매신청채권자가 경매신청의 기초가 된 담보물권(근저당권)을 말소하여 주어 담보권의 등기가 말소된 등기사항증명서를 민사집행법 266조 1항 1호의 집행취소서류로 제출한 경우, ㉡ 경매신청채권자가 경매신청의 기초가 된 담보물권(근저당권)을 말소하여 주지 않아 채무자가 채권자를 상대로 채무부존재확인소송이나 저당권말소청구소송을 제기하고 수소법원으로부터 경매절차의 일시정지를 명하는 잠정처분을 받은 다음 승소확정판결의 정본을 같은 조 1항 2호의 집행취소서류로 제출하거나, 승소확정판결에 기하여 근저당권을 말소한 다음 근저당권이 말소된 등기사항증명서를 같은 조 1항 1호의 집행취소서류로 제출한 경우, ㉢ 채무자의 임의경매개시결정에 대한 이의에 의하여 경매절차취소결정이 확정된 경우(대결 2000. 6. 28. 99마7385 참조)에는 최고가매수신고인 또는 매수인 등의 동의가 없더라도 경매절차가 취소된다.

위 ㉰의 요건은 우선변제권 취득 시에만 구비하면 족한 것이 아니고, 민사집행법상 배당요구의 종기까지 계속 존속하고 있어야 한다(주택의 경우, 대판 1997. 10. 10. 95다44597, 대판 2007. 6. 14. 2007다17475. 상가의 경우, 대판 2006. 1. 13. 2005다64002, 대판 2006. 10. 13. 2006다56299). 배당요구의 종기가 연기된 때에는 연기된 배당요구의 종기까지 존속하여야 한다.

㉱ 임차목적물에 관하여 소유권보존등기가 되어 있어야 하는 것은 아니다.

대항요건 및 확정일자를 갖춘 임차인과 소액임차인에게 우선변제권을 인정한 주택임대차보호법 3조의2 및 8조가 미등기 주택을 달리 취급하는 특별한 규정을 두고 있지 아니하므로 대항요건 및 확정일자를 갖춘 임차인과 소액임차인의 임차주택 대지에 대한 우선변제권에 관한 법리는 임차주택이 미등기인 경우에도 그대로 적용된다[대판(전) 2007. 6. 21. 2004다26133 참조].

다만 동일목적물에 임차권등기가 되어 있는 경우 그 이후에 임차한 임차인은 소액보증금 최우선변제권이 없고(주임 3조의3 6항, 상임 6조 6항), 민법 621조에 의한 임차권등기가 되어 있는 경우에도 같다(주임 3조의4 1항, 상임 7조 1항).

2) 확정일자를 갖춘 임차보증금채권의 우선변제권의 요건

위 1)의 각 요건 중 ㉮, ㉱의 요건과 임대차계약서에 확정일자를 갖춰야 한다. 다만 이 확정일자를 갖춘 임차인으로서 배당을 받는 경우에도 위 ㉰의 요건, 즉 첫 경매개시결정등기 전에 대항요건을 갖춰야 하는가에 대하여는, 소액보증금 최우선변제권의 경우와는 달리 첫 경매개시결정등기 이후에 갖추어도 된다는 것이 다수설이다.

3) 임차권등기를 한 자의 우선변제권의 요건

① 주택임대차보호법 3조의3 또는 상가건물 임대차보호법 6조에 따라 법원의 임차권등기명령에 의하여 등기되었거나 또는 민법 621조의 규정에 의하여 등기된 임차권일 것(주임 3조의3 5항 본문, 3조의4 1항, 상임 6조 5항 본문, 7조 1항, 다만 민법 621조의 규정에 의하여 등기된 임차권 중 임차보증금이 상가건물 임대차보호법상의 상한을 넘는 경우에는 민법 621조 2항의 대항력만 인정되고 우선변제권이 인정되지 않으므로 제외된다)

(마) 임차목적물의 인도(점유)

주택임차인의 경우에, 주택임대차보호법 3조 1항의 대항력은 임차인이 당해 주택에 거주하면서 이를 직접 점유하는 경우뿐만 아니라 타인의 점유를 매개로 하여 이를 간접점유하는 경우에도 인정될 수 있다(대판 2001. 1. 19. 2000다55645, 대판 2007. 11. 29. 2005다64255). 그러나 이 경우 후술하는 주민등록전입신고와 관련하여 주의하여야 한다.

한편 대법원은 앞서 본 바와 같이 주택임대차보호법상 소액임차인 등의 우선변제권의 요건인 주택의 점유(인도)와 주민등록은 민사집행법상 배당요구의 종기까지 계속 존속하고 있어야 한다는 입장이다(대판 2007. 6. 14. 2007다17475 등). 다만 주택임차권등기를 마친 후에는 그렇지 아니하다.

그리고 위의 요건은 주택임대차보호법 8조 1항의 소액보증금뿐 아니라 같은 법 3조의2 2항의 우선변제권에도 그대로 적용된다는 것이 통설인데, 상가건물임대차보호법 14조 1항의 소액보증금과 같은 법 5조 2항의 우선변제권에도 그대로 준용된다고 할 것이다(대판 2006. 1. 13. 2005다64002, 대판 2006. 10. 13. 2006다56299).

(바) 주민등록(전입신고) 또는 사업자등록신청

1) 주민등록 또는 사업자등록신청 명의자

① 주민등록은 임차인 본인의 주민등록만이 아니라 그 배우자나 자녀 등 가족의 주민등록을 포함한다(대판 1998. 6. 12. 98다5968, 대판 2002. 3. 29. 2001다84435 등). 이러한 법리는 재외국민이 임차인인 경우에도 마찬가지로 적용된다(대판 2016. 10. 13. 2015다14136, 대판 2016. 10. 13. 2014다218030, 218047).

② 주택임차인이 임차주택을 직접 점유하여 거주하지 않고 그곳에 주민등록을 하지 아니한 경우라 하더라도, 임대인의 승낙을 받아 적법하게 임차주택을 전대하고 그 전차인이 주택을 인도받아 자신의 주민등록을 마친 때에는, 이로써 당해 주택이 임대차의 목적이 되어 있다는 사실이 충분히 공시될 수 있으므로, 임차인은 주택임대차보호법에 정한 대항요건을 적법하게 갖추었다고 볼 것이다

여기에서 '주택의 인도'는 임차목적물인 주택에 대한 점유의 이전을 말한다. 이때 점유는 사회통념상 어떤 사람의 사실적 지배에 있다고 할 수 있는 객관적 관계를 가리키는 것으로서, 사실상의 지배가 있다고 하기 위해서는 반드시 물건을 물리적·현실적으로 지배할 필요는 없고, 물건과 사람의 시간적·공간적 관계, 본권관계, 타인의 간섭가능성 등을 고려해서 사회통념에 따라 합목적적으로 판단하여야 한다(대판 2003. 11. 14. 2001다78867, 대판 2005. 9. 30. 2005다24677 등 참조). 임대주택을 인도하는 경우에는 임대인이 임차인에게 현관이나 대문의 열쇠를 넘겨주었는지, 자동문 비밀번호를 알려주었는지, 이사를 할 수 있는지 등도 고려하여야 한다(대판 2017. 8. 29. 2017다212194).

소액임차인으로서 최우선변제를 받기 위해서는 첫 경매개시결정등기 전에 위 요건을 갖추어야 하고(주임 8조 1항, 상임 14조 1항), 배당요구의 종기까지 위 요건을 유지하여야 한다(주택의 경우, 대판 1997. 10. 10. 95다44597, 대판 2007. 6. 14. 2007다17475. 상가의 경우, 대판 2006. 1. 13. 2005다64002, 대판 2006. 10. 13. 2006다56299).

③ 확정일자를 갖춘 임차인의 우선변제권은 대항요건 및 확정일자를 모두 갖춘 때에 발생한다. 확정일자를 갖춘 후 보증금을 인상한 경우 인상한 보증금에 대하여는 새로 확정일자를 갖춰야 그때부터 우선변제권이 발생한다. 다만 임차권등기명령의 집행에 의한 임차권등기가 되면 임차인은 그때 대항력과 주택임대차보호법 3조의2 2항 또는 상가건물 임대차보호법 5조 2항의 확정일자를 갖춘 임차인으로서의 우선변제권을 취득한다.

주택의 임차인이 임대차계약서에 확정일자를 갖춘 당일 또는 그 후에 주택의 인도와 주민등록을 마친 경우에는 우선변제권은 주택의 인도와 주민등록을 마친 익일 영시에 발생한다(대판 1999. 3. 23. 98다46938, 대판 2000. 4. 11. 98다50791 등). 따라서 위와 같은 경우에 인도와 주민등록을 마친 다음날 설정된 저당권과의 관계에서는 확정일자를 갖춘 임차인이 우선한다.

상가건물의 경우에도 같다고 해석하여야 할 것이다(상임 3조 1항 참조).

주택 또는 상가건물의 임차인으로서 대항요건을 갖춘 다음날 오전 영시 이후

에 확정일자를 받았는데 확정일자를 받은 날에 저당권이 설정된 경우 확정일자를 받은 때와 저당권이 설정된 때가 명백히 판명되지 않는다면 임차인과 저당권자의 우선순위는 같으므로 평등하게 배당받는다. 이때 근저당권자가 여러 명이고 여러 건의 근저당 모두에 대하여 임차인의 우열이 판명되지 않는 경우에는 각 채권액에 비례하여 먼저 안분배당을 하고 저당권자 상호 간에는 선순위저당권자가 후순위저당권자의 배당액을 흡수하는 것으로 처리한다.

확정일자를 갖춘 임차인으로서 배당받는 경우에는 소액임차인으로서 배당받는 경우와는 달리 경매개시결정등기 이후 위 요건을 갖추어도 되지만(다수설), 배당요구의 종기까지 위 요건을 유지하여야 함은 소액임차인의 경우와 같다.

④ 상가건물의 임차인이 상가건물 임대차보호법 3조에서 정한 대항력을 취득한 다음 공유물 분할을 위한 경매절차에서 건물의 소유자가 변동된 경우 양수인이 임대인의 지위를 당연 승계하지만 소유권이 이전되기 전에 이미 발생한 연체차임이나 관리비 등 채권은 별도의 채권양도절차가 없는 한 원칙적으로 양수인에게 이전되지 않는다(대판 2017. 3. 22. 2016다218874 참조).

어떠한 목적물에 관하여 임차인이 상가건물 임대차보호법상의 대항력 또는 우선변제권 등을 취득한 후에 그 목적물의 소유권이 제3자에게 양도되면 임차인은 그 새로운 소유자에 대하여 자신의 임차권으로 대항할 수 있고, 새로운 소유자는 종전 소유자의 임대인으로서의 지위를 승계한다(상임 3조 1항, 2항, 5조 2항 등 참조). 그러나 임차권의 대항력 등을 받는 새로운 소유자라고 할지라도 임차인과의 계약에 기하여 그들 사이의 법률관계를 그들의 의사에 좇아 자유롭게 형성할 수 있는 것이다. 따라서 새로운 소유자와 임차인이 동일한 목적물에 관하여 종전 임대차계약의 효력을 소멸시키려는 의사로 그와는 별개의 임대차계약을 새로이 체결하여 그들 사이의 법률관계가 이 새로운 계약에 의하여 규율되는 것으로 정할 수 있다. 그리고 그 경우에는 종전의 임대차계약은 그와 같은 합의의 결과로 그 효력을 상실하게 되므로, 다른 특별한 사정이 없는 한 이제 종전의 임대차계약을 기초로 발생하였던 대항력 또는 우선변제권 등도 종전 임대차계약과 함께 소멸하여 이를 새로운 소유자 등에게 주장할 수 없다